

1500361-40.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/09/2022

... ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500361-40.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500361-40.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2045802/2020 - Delegacia de Polícia de Suzano, 10083874 - Delegacia de Polícia de Suzano, 852/20/309 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Sergio Rodrigues dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de BRUNO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS (nascido em 07/08/1990), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, em 17/02/2020, por volta das 21h40, na Rua Antônio Augusto Claro, nº 639, Jardim Lincoln, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu teria guardado e mantido em depósito, para entrega a consumo de terceiros, nas imediações de estabelecimento de ensino, 12 (doze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 4,31g (quatro gramas e trinta e um decigramas), e 26 (vinte e seis) porções de maconha, pesando aproximadamente 71,06g (setenta e um gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 812,00 em espécie, celulares e simulacro de arma de fogo (fls. 01/03).

Em 18/02/2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 50/53).

Laudos periciais juntados às fls. 109/112, 113/115, 116/121, 126/128 e 169/174.

O Réu apresentou defesa prévia em 13/03/2020 (fls. 122/125).  
Em 27/03/2020, foi recebida a denúncia (fls. 131/136).  
Concedida liberdade provisória ao Réu em 29/06/2020 (fls.199/200).  
Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu (fls. 265/266), sendo determinada a instauração de incidente para avaliação de dependência químico-toxicológica.  
Em 24/05/2022, foi declarado prejudicado o incidente para avaliação de dependência químico-toxicológica do Réu e encerrada a instrução (fls. 269).  
Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 274/281).  
A Defesa pugna (i) pela absolvição, devido à inadmissibilidade das provas produzidas nos autos (art. 157, § 1º, CPP), ou, subsidiariamente, (ii) pelo reconhecimento da primariedade do Réu e (iii) pela aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006 (fls. 290/295).

É o relatório.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Não há demonstração da materialidade delitiva, ante a ilegalidade das provas colhidas quando do flagrante, que contamina todas as outras provas produzidas nos autos.

A testemunha Robson Feitosa dos Santos, guarda civil municipal, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento juntamente com seu parceiro, quando receberam uma denúncia anônima de que dois indivíduos estariam arrastando, à força, uma mulher, para dentro de uma casa inabitada. No local, o portão da residência estava aberto e o quintal tinha traços de abandono. Entraram no imóvel e, ao notarem movimentação em seu interior, se identificaram. O Réu, então, saiu, sendo cientificado da denúncia e solicitado que permitisse a entrada dos policiais na residência. Permitida a entrada, no interior da casa sentiram um forte odor de maconha e encontraram uma mulher, que se identificou como sua esposa, e uma criança, filha do casal. Em cima da cama, havia um simulacro de arma e toucas ninja. Perguntaram sobre o cheiro, tendo o Réu confessado o uso de maconha e a existência de mais drogas no armário. Em averiguação, encontraram maconha, cocaína, dois celulares e cerca de R\$ 812,00 (oitocentos e doze reais) em notas trocadas. O Réu, então, confessou informalmente o tráfico de drogas (fls. 265/266).

A testemunha Eduardo de Souza Prado, guarda civil municipal, em juízo, afirmou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento, quando receberam uma denúncia de que, no local, uma mulher havia sido arrastada à força para dentro da residência, aparentemente abandonada. O portão estava aberto e não havia nenhuma iluminação interior. Quando foram entrar no imóvel, viram uma movimentação, então, chamaram o Réu. Questionaram o Réu sobre a denúncia, que foi por ele negada, sendo permitida a entrada no imóvel para que verificassem. Lá dentro, viram uma mulher e uma criança, além de um simulacro de arma e um forte odor de maconha. Questionado, o Réu informou que havia acabado de fumar e que havia mais droga na residência, dentro do armário. No móvel, foi encontrada maconha, além de uma quantia de dinheiro em notas baixas e duas toucas ninja. Depois disso, o Réu confessou informalmente a venda das substâncias (fls. 265/266).

A testemunha Greicy Kelly Silva dos Santos, em juízo, afirmou que não sabe nada sobre a prisão do Réu. É sua vizinha e viu o momento em que os guardas chegaram. Estava em sua residência, quando viu as luzes da viatura. Quando foi abrir o portão de sua casa, viu um policial, negro, pulando o muro do imóvel do Réu, enquanto outro, branco, estava no portão da casa. Não sabe o que aconteceu no interior da casa do Réu. Sobre a profissão do Réu, tinha a informação de que ele vendia água nos semáforos e ajudava sua esposa no buffet. Informou, ainda, que a casa é realmente do Réu, onde anteriormente moravam também seus pais e irmãos. Naquele dia, não ouviu nenhum grito, nem viu atitude suspeita na rua (fls. 265/266).

Interrogado, o Réu informou que, na data dos fatos, perto das 21h30, estava com sua

esposa e filha em casa, quando ouviram seu cachorro latir. Foi à janela verificar o que estava acontecendo e viu um dos guardas tentando abrir o cadeado do portão. Como não conseguiu, o guarda escalou e pulou o muro. O Réu foi avisar sua esposa que a “polícia” havia entrado no imóvel, e quando foi verificar novamente, os guardas já estavam na janela de seu quarto. Perguntou quem estava lá, sendo informado que era a “polícia” e solicitado que abrisse a porta. Havia usado maconha no local e, por isso, quando abriu a porta de sua casa, o “policia” realmente pôde sentir o cheiro. Questionado pelos agentes, o Réu informou que havia droga na residência. Afirma que é usuário e que, devido ao seu vício, adquiriu uma dívida, sendo obrigado a vender aquela droga para quitá-la. As drogas estavam dentro de uma caixa de som, no armário. O simulacro de arma de fogo, que disparava bolinhas de plástico, foi encontrado em sua casa, tendo sido entregue a ele pelos traficantes. Já a touca ninja, na outra casa que fica no mesmo terreno. Do dinheiro encontrado, parte era fruto do tráfico e parte da venda de biscoitos de sua esposa. Sobre suas características pessoais, informou que possui 30 (trinta) anos, é alfabetizado e está desempregado (fls. 265/266).

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia que os guardas civis municipais foram até a residência do Réu, sem mandado judicial, durante o período noturno, por terem recebido uma denúncia anônima de sequestro/cárcere privado, invadindo a residência e realizando busca no imóvel sem qualquer atribuição legal.

Os agentes públicos, em suas oitivas, afirmam que receberam uma denúncia anônima a respeito de um sequestro/agressão que ocorria em um imóvel e, sem chamar qualquer força de segurança pública, resolveram, por conta própria, ir até o local e averiguar, em atividade que foge ao escopo de sua função de guarda municipal. A guarda civil municipal não integra as forças de segurança pública, conforme se extrai do art. 144, CF, que apenas prevê, em seu § 8º, a possibilidade de os Municípios instituírem guardas para a proteção de seus bens, serviços e instalações.

Na espécie, nenhum bem ou interesse municipal estava em jogo e os guardas não presenciaram qualquer situação flagrancial, que poderia permitir a sua atuação como qualquer pessoa do povo. Foram ao imóvel objeto da denúncia anônima e, lá chegando, não verificaram nada de errado. Chamando o Réu e vendo que sua mulher e filho estavam bem, ainda assim resolveram seguir com uma investigação por suposto tráfico de drogas – crime que não foi objeto da mencionada denúncia anônima – entrando na casa do Réu, de noite, sem mandado e sem atribuição para tanto.

Não se olvida que há farta jurisprudência que legitima a prisão e as provas colhidas em razão de abordagens realizadas por guardas civis municipais em casos de tráfico de drogas, sendo, inclusive, aceita essa corrente por este Magistrado. Todavia, a aplicação dessa corrente jurisprudencial se funda única e exclusivamente na possibilidade de qualquer pessoa do povo prender outra em flagrante. Ou seja, para que a ação dos guardas civis municipais seja lícita, é preciso que exista estado flagrancial evidente, não que seja necessária investigação prévia a respeito do que está, de fato acontecendo. Se os guardas, atendendo à denúncia anônima, não encontram nada de ilícito, a conduta correta, se suspeitam que seja necessária maior investigação, é acionar a Polícia Civil ou a Polícia Militar, que têm atribuição constitucional para atuar na segurança pública.

Esse é o recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto

constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil – em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência – estão sujeitas a rígido controle correccional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais – apesar da sua relevância – não estão sujeitas a nenhum controle correccional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar – em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais – o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim,

permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12. Recurso especial provido” (STJ, REsp nº 1977119/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/08/2022)

Ainda que se entenda pela legitimidade da atuação dos guardas municipais, ficou evidente que o domicílio do Réu foi violado por eles, que não possuíam nenhum dos motivos autorizadores do art. 5º, XI, CF, para tanto.

Explico.

A inviolabilidade do domicílio é uma garantia constitucional, constitui direito individual de 1ª geração e, por isso, exige uma conduta negativa do Estado.

Significa que o aparato estatal não pode agir fora das hipóteses permissivas: para prestar socorro, por determinação judicial (durante o dia) ou nas duas hipóteses que poderiam se encaixar nesse caso, o flagrante delito e o consentimento do morador.

A hipótese de flagrante delito não se sustenta, conforme anteriormente exposto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, vem entendendo que, tanto a denúncia anônima como único indício, quanto o odor de maconha por si só, não permitem a entrada da força policial no domicílio:

“HABEAS CORPUS. ARTS. 33, 35 E 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N.

10.826/2003. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CONTEXTO FÁTICO APTO A SUBSIDIAR A CONVICÇÃO OU MESMO FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA (APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO) E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO 1. Esta Corte tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente a

ocorrência de um crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente. 2. No caso, verifica-se que o ingresso no domicílio do paciente foi amparado tão somente em denúncia anônima, sem referência a prévia investigação, monitoramento ou campanhas a indicar que se tratava de averiguação de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo se por outras razões estiver detido (Processo n. 5005205-21.2021.8.21.0165, em curso na Vara Judicial da comarca de Eldorado do Sul/RS)." (HC n. 721.911/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CHEIRO DE DROGA E NERVOSISMO DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

[...]. 3. A lógica da alegação dos policiais de que sentiram forte cheiro de drogas vindo do interior da residência é, de certa forma, revestida de alto grau de subjetivismo do agente estatal que irá realizar a busca e, sendo uma circunstância oriunda simplesmente do relato do próprio agente que realiza a medida invasiva, deve ser sujeito a rigoroso escrutínio a posteriori pelo Judiciário, mediante cuidadosa avaliação do contexto fático que circunscreveu a diligência.

4. Nos casos, por exemplo, em que os policiais responsáveis pelo ingresso em determinado domicílio afirmam haverem feito campanhas no local, visto movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas ou visto alguém entregando algum objeto aparentemente ilícito para outrem, há descrição de elementos objetivos e com maior grau de sindicabilidade, de modo que, ainda que também dependam, de certa forma, da credibilidade do relato do policial, podem ser atestados - ou confrontados e infirmados - por outros meios, como a gravação audiovisual por câmeras. No entanto, quando o ingresso se baseia apenas na afirmação do policial de haver cheiro de drogas exalando da residência, o grau de subjetividade é tamanho que, mesmo se registrada toda a diligência em áudio-vídeo, não há como captar o odor mencionado a ponto de demonstrar objetivamente a fiabilidade da suspeita prévia.

5. Ao se analisar se havia ou não justa causa para a entrada dos policiais em domicílio alheio, é preciso avaliar - com escrutínio ainda mais rigoroso - o contexto de apreensão das drogas, a fim de verificar, com a segurança necessária, se realmente era verossímil a justificativa policial para o ingresso em domicílio, sob pena de se tornar praticamente incontrastável pela defesa - e também incontrolável pelo Judiciário - a afirmação do agente público.

[...]. 8. O simples relato dos policiais de que sentiram forte cheiro de droga vindo do interior da residência, desprovido de qualquer outra justificativa mais elaborada, não configurou, especificamente na hipótese sub examine - em que o contexto fático retira a verossimilhança da narrativa dos militares -, o elemento "fundadas razões" necessário para o ingresso no domicílio do réu. 9. Conforme tem reiteradamente decidido esta Corte Superior de Justiça, atitude considerada suspeita e nervosismo do acusado ao avistar os policiais não constituem justa causa a autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial.

[...]. 13. Ordem concedida para, considerando que não houve fundadas razões, tampouco comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio do paciente, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, conseqüentemente, absolvê-lo em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP." (HC n. 697.057/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/3/2022)

No caso em análise, não só a entrada no imóvel se deu em razão somente de denúncia

anônima, como só teria sido possível sentir o odor da substância através da entrada ilegal no terreno do Réu. Como se vê, não houve campana, visualização de movimentação típica da venda de drogas na residência ou qualquer outra circunstância que permitisse a violação do domicílio, pois ausentes fundadas razões.

Da mesma forma, a hipótese de franqueamento de entrada no domicílio pelo Réu não foi comprovada. As únicas provas nos autos são os depoimentos dos guardas civis municipais - que, frisa-se, não possuem atribuição para policiamento ostensivo ou para investigação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples afirmativa dos agentes públicos de que o Réu teria permitido sua entrada no imóvel não basta para comprovar essa permissão, que deve ser obtida documentalmente, por vídeo e/ou por áudio:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

[...]. 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio.

6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento "deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção [...]. (*United States v McCaleb*, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977) [...]. Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (*totality of circumstances*)).

6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito.

6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (*North Carolina v. Butler* (1979) 441 U.S. 369, 373; [...]).

6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa - ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção -, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, "necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis" (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO).

6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal - analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial - ao dispor que, "[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º".

[...]. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da

diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.

[...]. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital. [...].” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Por todo o exposto, conclui-se que a prova obtida por meio da entrada no domicílio do Réu é ilegal. Assim sendo, pela inadmissibilidade das provas derivadas das ilícitas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (“fruit of the poisonous tree”), as produzidas durante a instrução também são inadmissíveis, pois se não houvesse a prisão ilegal, não haveria instauração do inquérito policial que originou esta ação penal.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória e absolvo o Réu BRUNO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, II, CPP, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. art. 40, III, Lei nº 11.343/06). Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias. Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 04 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA